

刑法
No130

共通問題 R1-13

(配点: 2)

月 日

月 日

学生A、B及びCは、次の【事例】における窃盗罪の実行の着手時期について、後記【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑥までの()内から適切なものを選んだ場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【事例】

甲は、X宅のタンスに宝石が保管されていることを知ったため、その宝石を窃取する目的で、X宅に玄関から侵入し、宝石が保管されているタンスの在りかを探し始めて、それが置かれていた居間に立ち入ろうとしたところ、居間から出てきたXと鉢合わせとなり、取り押さえられた。

【会話】

学生A. 私は、甲がX宅に侵入した時点で窃盗罪の実行の着手を認めてよいと思います。この時点で、①(a. 犯意の飛躍的表動があった・b. 法益侵害の危険が飛躍的に高まった)といえるからです。

学生B. A君は、犯罪を行為者の危険な性格の発現であると考えているのですね。私は、実行の着手の「実行」とは構成要件該当行為のことで、「着手」とはそれを開始することだと解するので、【事例】では、窃盗罪の実行の着手は、②(c. 認められない・d. 居間に立ち入ろうとした時点で認められる)と考えます。

学生A. B君の見解に対しては、実行の着手時期が③(e. 不明確になる・f. 遅くなり過ぎる)との批判がありますね。

学生C. 私は、実行の着手時期とは、未遂犯の成立時期のことであるので、未遂犯の処罰根拠に遡り、実質的に考えることが必要だと思います。そのため、窃盗罪の実行の着手時期は、④(g. 占有侵害の現実的危険性が発生した・h. 窃取行為と密接に関連する行為を開始した)時点だと解するので、【事例】では、窃盗罪の実行の着手は、⑤(i. 認められない・j. X宅内でタンスの在りかを探し始めた時点で認められる)と考えます。この点、B君の見解を修正し、実行の着手時期を⑥(k. 占有侵害の現実的危険性が発生した・l. 窃取行為と密接に関連する行為を開始した)時点とする見解もありますが、この見解に対しては、形式面を重視すると言いながら、結局、実質的な観点を取り入れているとの批判があります。

1. ①a ⑥k 2. ②c ④h 3. ②d ⑤i 4. ③f ⑥l 5. ④g ⑤j

No.130	窃盗罪の実行の着手時期	正答率
共通R1-13	正解	60%
	4	

() には、順に「①a ②c ③f ④g ⑤i ⑥l」が入り、正解は肢4となる。

①について

学生Aは、【事例】の甲が、X宅に侵入した時点で窃盗罪の実行の着手を認めてよいと発言している。宝石は、X宅のタンスの中に保管されているから、甲がX宅に侵入しただけでは窃盗罪の法益侵害の危険、すなわち占有移転の危険性は生じていない。よって、①には、「b. 法益侵害の危険が飛躍的に高まった」は入らない。また、直後に学生Bは、「A君は、犯罪を行為者の危険な性格の発現であると考えているのですね」と発言している。犯罪を行為者の危険な性格の発現と考えるのは、主観説の立場である。したがって、①には、「a. 犯意の飛躍的表動があった」が入る。

②について

学生Bは、「実行の着手の『実行』とは構成要件該当行為のことで、『着手』とはそれを開始することだ」と発言している。これは、形式的客観説の立場である。形式的客観説の立場からすると、窃盗罪の実行行為は、他人の財物を窃取すること、すなわち占有者の意思に反して財物の占有を移転させることをいうから、占有移転の開始が窃盗罪の実行の着手ということになる。【事例】においては、宝石に手を伸ばした行為が、これに当たる。よって、宝石が保管されているタンスが置かれている居間に立ち入ろうとした時点では、実行の着手は認められない。したがって、②には、「c. 認められない」が入る。

③について

学生Bの見解、すなわち形式的客観説は、形式的な実行行為の概念に着目して実行の着手を定義する見解である。これによると、形式的な実行行為概念を基軸とすることにより、実行の着手の有無を比較的明確に判断し得るというメリットがある。よって、実行の着手時期が「e. 不明確になる」との批判は妥当しない。また、形式的客観説に対しては、実行の着手の有無の判断が硬直的になり、実行の着手時期が遅くなりすぎるとの批判がある。例えば、【事案】においては、上述のように宝石に手を伸ばした行為が実行の着手となるが、それ以前の物色行為が実行の着手でないとすると、家中を物色して歩いても窃盗未遂罪(243条・235条)が成立しないこととなり、窃盗予備は不可罰であることから、このような帰結は妥当でないと批判されている。したがって、③には、「f. 遅くなり過ぎる」が入る。

④について

学生Cは、「実行の着手時期とは、未遂犯の成立時期のことであるので、未遂犯の処罰根拠に遡り、実質的に考えることが必要だ」と発言している。よって、学生Cの立場は、実質的客観説、すなわち、結果発生の実質的危険性のある行為を開始することを実行の着手と考える見解である。したがって、④には、「g. 占有侵害の実質的危険性が発生した」が入る。

⑤について

⑤は、学生Cの見解すなわち実質的客観説の立場から、【事例】において、窃盗罪の実行の着手、すなわち占有侵害の実質的危険性が認められる時期を問うものである。【事例】では、甲は宝石がタンスの中に保管されていることを知っていたものの、タンスの在りかは知らなかった。そうすると、たとえタンスが居間に置かれていたとしても、居間に立ち入ろうとした時点では、未だ占有侵害の実質的危険性は生じていないといえる。したがって、⑤には、「i. 認められない」が入る。

⑥について

⑥には、学生Bの見解、すなわち形式的客観説を修正し、かつ、「形式面を重視すると言いつながら、結局、実質的な観点を取り入れている」と批判し得る見解からの実行の着手時期に関する語句が入る。kの窃盗罪の実行の着手時期を「占有侵害の現実的危険性が発生した」時点とする見解は、実質的客観説そのものであり、形式的客観説を修正している見解とはいえない。他方、lの窃盗罪の実行の着手時期を「窃取行為と密接に関連する行為を開始した」時点とする見解は、「窃取行為」という形式的に構成要件に該当する行為を実行の着手時期とする形式的客観説に対して、密接に関連する行為という実質的な観点を取り入れてこの説を修正している見解といえる。したがって、⑥には、「l. 窃取行為と密接に関連する行為を開始した」が入る。